刑法15 筆記：必要參與犯（聚合犯與對向犯）

> 來源：刑法15 課程字幕 01:02:00 ~ 01:22:00

🕮 法條原文速查

> **§136**（聚眾妨害公務罪）
> 公然聚眾犯前條之罪者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；**首謀**及**下手實施**者，處一年以上七年以下有期徒刑。
> → 建議查閱最新六法原文

> **§239**（通姦罪）【已除罪化（釋字 791）】
> 有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。
> → 對向犯之經典範例（雙方同罰），已宣告違憲

> **§122**（受賄罪相關）
> → 行賄/受賄：對向犯之「雙方罰，但刑度不同」範例

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「聚合犯中不同角色之間能否成立共同正犯？」	**同程度**可論共正（如首謀之間）；**不同程度**各論各的
「對向犯的相對人能否論共同正犯？」	**不可**（內部關係）
「對向犯中只罰一方時，未罰一方能否論教唆犯？」	**不可**，不得以迂迴方式論共犯
「對向犯外部第三人能否論共犯？」	**可以**（外部關係不受限制）
「聚眾妨害公務中，首謀與下手施暴者是否成立共同正犯？」	**不成立**共正（不同程度各論各的）

正文

一、必要參與犯的分類

```
必要參與犯
├── 聚合犯：多人朝「同一方向」目標行為
│     └── 例：聚眾妨害公務（§136）
│
└── 對向犯：雙方處於「對立合致」地位
      └── 例：通姦（§239）、行賄/受賄（§122）
```

二、聚合犯

定義

多數人朝**同一方向**共同從事某種犯罪行為，法律依照參與程度給予不同評價。

§136 聚眾妨害公務的三種角色

角色	定義	法律效果
首謀	策劃、指揮者	1-7 年
下手實施	直接動手施暴者	1-7 年
在場助勢	在場壯聲勢但未動手	1 年以下

聚合犯的共同正犯問題

```
聚合犯中共正的成立
├── 同程度角色之間 → 可成立共同正犯
│     例：兩個首謀之間 → 可論共正
│     例：兩個下手實施者之間 → 可論共正
│
└── 不同程度角色之間 → 不成立共正，各論各的
      例：首謀 vs 在場助勢 → 各依自己的角色論罪
```

三、對向犯

定義

犯罪之成立需要雙方行為**對立合致**，如一方賣、一方買；一方行賄、一方受賄。

三種型態

型態	說明	範例
雙方同罰	雙方處同等刑度	通姦罪（§239，已違憲）
雙方罰，刑度不同	雙方皆罰但輕重有別	行賄/受賄
只罰一方	立法者有意僅處罰一方	販賣犯罪（罰賣方，不罰買方）

對向犯的共犯成立限制

內部關係（相對人之間）

```
對向犯相對人之間
├── 共同正犯 → ✗ 不可
├── 教唆犯 → ✗ 不可
└── 幫助犯 → ✗ 不可
```

> **理由**：對向犯的結構本來就預設有相對人存在，如果相對人的參與行為可以另論共犯，等於「雙重評價」或「迂迴處罰立法者有意不罰之人」，違反立法意旨。

「只罰一方」型態的特殊問題

- 立法者**有意**不罰另一方 → 另一方不得以教唆犯、幫助犯等方式被迂迴處罰
- 例：販賣毒品罰賣方，不罰買方 → 買方不能被論為賣方的教唆犯

外部關係（第三人）

```
對向犯的外部第三人
├── 教唆犯 → ☑ 可成立
├── 幫助犯 → ☑ 可成立
└── 共同正犯 → ☑ 可成立
```

- 非屬對向犯結構內的第三人，其參與行為不受對向犯理論限制
- 例：丙教唆甲行賄 → 丙可成立行賄罪之教唆犯

四、內部 vs 外部關係速查

關係	能否論共犯	說明
對向犯**相對人之間**	✗ 不可	內部關係，受對向犯理論限制
對向犯**外部第三人**	☑ 可以	外部關係，不受限制

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§136	聚眾妨害公務	聚合犯經典範例
§239	通姦罪（已違憲）	對向犯「雙方同罰」範例
§122	受賄罪	對向犯「雙方罰刑度不同」範例
§28	共同正犯	聚合犯中共正之成立
§29	教唆犯	對向犯內部不可論教唆
§30	幫助犯	對向犯內部不可論幫助

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
釋字 791	通姦罪（§239）違憲，宣告失效